

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 464/2541 บริษัท เซ็น ทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
นาย สุนันท์ สุนทรรัตน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 มาตรา ข้อ 40

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4, มาตรา 31, มาตรา 40, มาตรา 42, มาตรา 50

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 มาตรา 35

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 84 วรรคสอง

อำนาจในการสั่งให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างผิดแบบแปลนจากที่ได้รับอนุญาต โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 40 และ 42 เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและตามมาตรา 4 เจ้าพนักงานท้องถิ่นหมายความว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครเมื่ออาคารของโจทก์ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก่อสร้างผิดแบบแปลนจากที่ได้รับอนุญาตโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 และ 42 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้โจทก์รื้อถอนอาคารได้ และเนื่องจากมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2518 ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นให้อำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทนได้ เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งมอบอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทนและได้ประกาศคำสั่งในกรุงเทพ กิจจานุเบกษาแล้ว ผู้อำนวยการ เขตพระนคร จึงมีอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้อำนวยการเขตพระนครมาลงชื่อในสมุดลงเวลาทำการในตอนเช้าแล้วไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพระนคร กรณีจึงถือได้ว่าในวันดังกล่าวจำเลยที่ 1 ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครและเป็นผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการจึงมีอำนาจปฏิบัติราชการในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระนคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 84 วรรคสอง การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารใดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 นั้น นอกจากจะ คำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยแล้ว ยังจะต้อง พิจารณาถึงแผนผัง บริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนด้วย ดังนั้น การที่โจทก์ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามแบบแปลนเพียง 4 ชั้น แต่กลับก่อสร้างเป็นอาคารถึง 6 ชั้นจึงเป็นการก่อสร้างที่ผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 31 และเมื่อเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้ก่อสร้างเป็นอาคาร 6 ชั้น ตามที่ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นไว้ในมาตรา 31(1)(2)และ (3) ได้ จึงชอบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้โจทก์รื้อถอนอาคารชั้นที่ 5 และชั้นที่ 6 ได้ ตามแผนผังบริเวณของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจะต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมเป็นทางเดินด้านหลังอาคารได้ถึงกันกว้าง 2 เมตร และด้านหลังของอาคารก็ไม่มีมีการก่อสร้างเชื่อมต่อกับอาคารของบริษัท ด. เพราะเป็นการก่อสร้างแตกต่างหากอาคารเดิมของบริษัท ด. การที่โจทก์ฝ่าฝืนก่อสร้างอาคารเชื่อมต่อกันปกคลุมที่ว่างด้านหลังโดยไม่หลบเขตเป็นทางเดินด้านหลังอาคารกว้าง 2 เมตรจึงขัดกับมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั้งยังขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 76(4) ด้วยจึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ จึงชอบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้โจทก์รื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างปกคลุมที่ว่าง

ทางเดินหลังอาคารทั้งหมดได้ อาคารที่ก่อสร้างตามใบอนุญาตที่ พ.28/2525 ซึ่ง
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินโฉนดเลขที่ 6139 และโฉนดที่ดินเลขที่ 6298 โจทก์ก่อสร้าง
อาคารบนที่ดินที่ซื้อมาจาก บ. ที่ดินดังกล่าวทางทิศเหนือจดที่ดินเลขที่ 156,157
และทางสาธารณะต่อมาที่ดินแปลงนี้ได้แบ่งแยกออกเป็นที่ดินแปลงย่อยอีก 6 แปลง
ซึ่งทางทิศเหนือของที่ดินแปลงย่อยที่แบ่งแยกออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 6137 และ
6138 ก็อยู่ติดทางสาธารณะต่อมาที่ดินโฉนดเลขที่ 6138 ถูกแบ่งแยกออกเป็น 2
แปลงอีกคือที่ดินแปลงทางทิศใต้โฉนดที่ดินเลขที่ 6298 ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่
6138(แปลงคงเหลือ) เป็นที่ดินแปลงทางทิศเหนือเนื้อที่ 0.4 ตารางวา ซึ่งยังติดทาง
สาธารณะอยู่เช่นเดิมถัดจากทางสาธารณะขึ้นไปทางทิศเหนือจะเป็นที่ดินโฉนดเลขที่
1184 เลขที่ดิน 21 พร้อมอาคารของโจทก์ซึ่งทางทิศตะวันออกจะติดกับอาคารของ
บริษัท ต. โจทก์ก่อสร้างอาคารของโจทก์ให้เชื่อมต่อกับอาคารของบริษัท ต. โจทก์ต้อง
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินโฉนดเลขที่ 6298 ปกคลุมที่ดินโฉนดเลขที่ 6138 และทาง
สาธารณะด้วย เพื่อให้ไปเชื่อมต่อกับอาคารบนที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 1184 และ
อาคารของบริษัท ต. ให้เป็นอาคารเดียวกัน ซึ่งขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ. 2522 ข้อ 69 เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้โจทก์
รื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนที่ก่อสร้างปกคลุมทางสาธารณะจึงชอบด้วย
กฎหมายแล้ว พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 50 กำหนดให้ปลัด
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร และในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 40 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่
29 กันยายน 2515 มีคำสั่งมอบอำนาจดังกล่าวให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่าย
บริหารปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในหน้าที่ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และปลัดกระทรวงมหาดไทยยังมีคำสั่งมอบอำนาจให้จำเลยที่
3 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานฝ่ายบริหารดังนั้น จำเลยที่ 3 ซึ่ง

ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานฝ่ายบริหาร จึงมีอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่จำเลยที่ 3 ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามเป็นเจ้าพนักงานของรัฐได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยมีชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือ จำเลยที่ 2 ซึ่งอ้างว่ารักษาราชการแทนจำเลยที่ 1 ได้มีคำสั่งให้โจทก์รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างผิดแบบแปลนจากที่ได้รับอนุญาต โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีจำเลยที่ 3 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เปลี่ยนแปลงคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อโจทก์ไม่ต้องรื้อถอนอาคาร คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยและมีคำสั่งแล้ว โจทก์เห็นว่า คำสั่งของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคำสั่งของจำเลยที่ 3 ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการเขตพระนครและจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครไม่ใช่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 เพราะกฎหมายบัญญัติให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ผู้เดียวในเขตกรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้โจทก์รื้อถอนดังกล่าวได้ และคำสั่งของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังเป็นคำสั่งที่ขัดต่อกฎหมายสำหรับจำเลยที่ 3 ไม่ใช่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ไม่ได้เพราะขัดต่อมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีผลบังคับให้โจทก์ต้องปฏิบัติตาม อาคารที่โจทก์ก่อสร้างมีความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงมีการป้องกันอัคคีภัยอย่างถูกต้องและมีการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีมิได้ขัดต่อผังเมืองและสถาปัตยกรรม ซึ่งโจทก์ปลูกสร้างและใช้อาคารมานานถึง 8 ปีแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีภัยอันตรายใด ๆ เกิดขึ้น การที่จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์รื้อถอนอาคารดังกล่าวทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้พิพากษาว่าคำสั่งที่ กท.9001/ยธ.6498 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2532 ที่จำเลยที่ 2 ลงนามไม่ชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 451-1/2534 ของจำเลยที่ 3 กับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้บังคับเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งให้โจทก์ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ยกคำสั่งของจำเลยที่ 2 และคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 3 กับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ด้วย

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยทั้งสามในฐานะเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้พิจารณาเห็นว่าการก่อสร้างอาคารของโจทก์ผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจึงใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมีคำสั่งและคำวินิจฉัยให้โจทก์ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์ซื้อที่ดิน โฉนดเลขที่ 1187 ซึ่งอาคารพิพาทตั้งอยู่จากหม่อมหลวงบัวต่อมาที่ดินดังกล่าวแบ่ง เป็นแปลงย่อยอีก 6 แปลงที่ดิน 2 แปลงใน 6 แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 6137 และ โฉนดเลขที่ 6138 ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวระบุทางทิศเหนือติดทางสาธารณะ ต่อ มาที่ดินโฉนดเลขที่ 6138 ถูกแบ่งแยกเป็น 2 แปลง แปลงที่ถูกแยกไปคือที่ดินโฉนด เลขที่ 6298 โจทก์เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองอาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้า พนักงานท้องถิ่นเลขที่ พ.4/2525 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2525 และเลขที่ พ.28/2525 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2525 ให้ทำการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น 2 หลัง เพื่อ ใช้เป็นอาคารพาณิชย์ที่ถนนพหลโยธิน อาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างผิดแบบแปลนจากที่ได้ รับอนุญาต จำเลยที่ 2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร จึงมีคำสั่งที่ กท 9001/ ยธ.6498 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2532 ให้โจทก์รื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างผิดแบบ แปลนจากที่ได้รับอนุญาต คือ

1. ตามแบบแปลนชั้นล่างหลบเขต 2 เมตร ก่อสร้างจริงหลบเขต 3 เมตร (ด้าน หน้าอาคารติดถนนพหลโยธิน)
2. ตามแบบแปลนกันสาดชั้นที่ 2 ถึง 4 ยื่น 1 เมตร ก่อสร้างจริงยื่นกันสาดทำ เป็นตัวอาคารยื่นออกมา 2.50 เมตร ทำให้หลบเขต 0.50 เมตร (ด้านหน้าอาคารติด ถนนพหลโยธิน)
3. ตามแบบแปลนด้านหลังอาคารหลบเขต 2 เมตร ก่อสร้างจริงไม่หลบเขต ทำให้ไม่มีทางเดินหลังอาคาร

4. ตามแบบแปลนได้รับอนุญาตเป็นอาคารตึก 4 ชั้นก่อสร้างจริงเป็นอาคารตึก 6 ชั้น

5. ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ด้านหลังปกคลุมทางสาธารณะ ขนาด 1.60 x 14.80 เมตร เป็นอาคารตึก 6 ชั้น

โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 3 ในฐานะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหารทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้วมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 451-1/2534

1. กลับคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นข้อ 1 และ 2 โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งให้โจทก์ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เฉพาะแนวอาคารชั้นล่างและแนวอาคารชั้นที่ 2 ถึง 4 ด้านถนนพาหุรัด

2. ยืนตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นข้อ 3 และ 4 เฉพาะอาคารส่วนที่ก่อสร้างปกคลุมที่ว่างทางด้านหลังอาคารทั้งหมดและอาคารชั้นที่ 5 และชั้นที่ 6

3. แก้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นข้อ 5 โดยให้รื้อถอนเฉพาะอาคารตึก 6 ชั้น ขนาด 1.60 x 7.40 เมตร

ปัญหาประการแรกที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครมีอำนาจออกคำสั่งที่ กท 9001/ยธ 6498 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2532 หรือไม่และคำสั่งที่ให้โจทก์รื้อถอนอาคารดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่า อำนาจในการสั่งให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างผิดแบบแปลนจากที่ได้รับอนุญาตโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 และ 42 เป็น

อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นหมายความว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเมื่ออาคารของโจทก์ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครก่อสร้างผิดแบบแปลนจากที่ได้รับอนุญาตโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 และ 42 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้โจทก์รื้อถอนอาคารได้และเนื่องจากมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นให้อำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทนได้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงมีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4084/2524 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2524 มอบอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทนตามข้อ 5.1 และได้ประกาศคำสั่งในกรุงเทพกิจจานุเบกษาแล้ว ผู้อำนวยการเขตพระนครจึงมีอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น อนึ่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 84 วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเป็นผู้รักษาราชการแทน คดีนี้จำเลยที่ 2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครลงชื่อในคำสั่งที่ กท 9001/ยธ 6498 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2532 ในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระนครซึ่งในวันที่ 31 สิงหาคม 2532 จำเลยที่ 1 มาลงชื่อในสมุดลงเวลาทำการในตอนเช้า แต่ไม่ได้ลงเวลากลับและได้ความจากจำเลยที่ 1 ว่า หลังจากลงเวลาในตอนเช้าแล้วก็ไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพระนคร กรณีจึงถือได้ว่าในวันดังกล่าว จำเลยที่ 1 ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครและเป็นผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ จึงมีอำนาจลงชื่อในคำสั่งที่ กท 9001/ยธ 6498 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2532 ในฐานะรักษา

ราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระนคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยที่ 2 สั่งให้โจทก์รื้อถอนอาคารโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น แต่ก่อสร้างเป็นอาคาร 6 ชั้น ตามแบบแปลนที่สถาปนิกและวิศวกรออกแบบและมีสถาปนิกควบคุมการก่อสร้างอาคารมีลักษณะมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้นั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารใดนั้น นอกจากจะคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงแผนผัง บริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนด้วย การที่โจทก์ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามแบบแปลนเพียง 4 ชั้น แต่กลับก่อสร้างเป็นอาคารถึง 6 ชั้น จึงเป็นการก่อสร้างที่ผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ห้ามมิให้กระทำเช่นนั้น และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้ก่อสร้างเป็นอาคาร 6 ชั้น ตามที่ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นไว้ในมาตรา 31(1)(2)และ (3) ได้ ที่จำเลยที่ 2 สั่งให้โจทก์รื้อถอนอาคารชั้นที่ 5 และชั้นที่ 6 จึงชอบแล้ว

ที่โจทก์ฎีกาว่า กรณีก่อสร้างอาคารโดยไม่หลบเขตเป็นทางเดินด้านหลังอาคารกว้าง 2 เมตร ก็เพราะได้ก่อสร้างเชื่อมต่อกับอาคารของบริษัทเตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด ซึ่งเป็นอาคารในเครือบริษัทเดียวกันเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จึงไม่จำเป็นต้องมีทางเดินด้านหลัง ถือว่าเป็นกรณีที่สามารแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้นั้น เห็นว่า ตามแผนผังบริเวณของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจะต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมเป็นทางเดินด้านหลังอาคารได้ถึงกันกว้าง 2 เมตร และด้านหลังของอาคารก็ไม่มีอาคารก่อสร้างเชื่อมต่อกับอาคารของบริษัทเตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด เพราะ

เป็นการก่อสร้างแยกต่างหากอาคารเดิมของบริษัทเตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด ดังนั้น การที่โจทก์ฝ่าฝืนก่อสร้างอาคารเชื่อมต่อกันปกคลุมที่ว่างด้านหลังโดยไม่หลบเขตเป็นทางเดินด้านหลังอาคารกว้าง 2 เมตร จึงขัดกับมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั้งยังขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 76(4) ด้วย จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ที่จำเลยที่ 2 สั่งให้โจทก์รื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างปกคลุมที่ว่างทางเดินด้านหลังอาคารทั้งหมดชอบแล้ว

ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มิได้ก่อสร้างอาคารปกคลุมทางสาธารณะเพราะที่ดินที่ก่อสร้างไม่มีทางสาธารณะผ่าน โจทก์ซื้อที่ดินที่ก่อสร้างอาคารมาจากหม่อมหลวงบัว ที่ดินดังกล่าวไม่มีทางสาธารณะผ่าน เห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับอาคารที่ก่อสร้างตามใบอนุญาตที่ พ.28/2525 ซึ่งก่อสร้างอาคารบนที่ดินโฉนดเลขที่ 6139 และโฉนดที่ดินเลขที่ 6298 โจทก์ก่อสร้างอาคารบนที่ดินที่ซื้อมาจากหม่อมหลวงบัว คือที่ดินโฉนดเลขที่ 1187 ซึ่งตามโฉนดที่ดินดังกล่าวก็ระบุอาณาเขตที่ดินทางทิศเหนือว่าจดที่ดินเลขที่ 156, 157 และทางสาธารณะด้วย ต่อมาที่ดินแปลงนี้ได้แบ่งแยกออกเป็นที่ดินแปลงย่อยอีก 6 แปลง ตามรูปแผนที่ที่ยื่นปรากฏชัดเจนว่าทางทิศเหนือของที่ดินแปลงย่อยที่แบ่งแยกออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 6137 และโฉนดที่ดินเลขที่ 6138 ติดทางสาธารณะ ต่อมาที่ดินโฉนดเลขที่ 6138 ถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 แปลงอีกคือที่ดินแปลงทางทิศใต้โฉนดที่ดินเลขที่ 6298 เนื้อที่ดิน 24.8 ตารางวา ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 6138 เป็นที่ดินแปลงทางทิศเหนือเนื้อที่ 0.4 ตารางวา ซึ่งยังติดทางสาธารณะอยู่เช่นเดิมและเมื่อพิจารณาแผนที่แสดงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารของโจทก์ประกอบด้วยแล้ว จะเห็นได้ว่าถัดจากทางสาธารณะขึ้นไปทางทิศเหนือจะเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 1184 พร้อมอาคารของโจทก์ ซึ่งทางทิศตะวันออกจะติดกับอาคารของบริษัทเตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด ดังนั้น การที่โจทก์ก่อสร้างอาคารของโจทก์ให้เชื่อมต่อกับอาคารของบริษัทเตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด ย่อมเห็นได้ชัดแจ้งว่าโจทก์ต้องก่อสร้างอาคารบนที่ดิน

โฉนดเลขที่ 6298 ปกคลุมที่ดินโฉนดเลขที่ 6138 และทางสาธารณะด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ไปเชื่อมต่อกับอาคารบนที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 1184 และอาคารของบริษัทเตียงจิราธิวัฒน์ จำกัด ให้เป็นอาคารเดียวกันซึ่งขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ. 2522 ข้อ 69 ที่จำเลยที่ 2 สั่งให้โจทก์รื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ส่วนที่ก่อสร้างปกคลุมทางสาธารณะจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ปัญหาสุดท้ายตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยที่ 3 ซึ่งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 50 กำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 40 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 137/2523 มอบอำนาจดังกล่าวให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และปลัดกระทรวงมหาดไทยยังมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 533/2533 ลงวันที่ 27 กันยายน 2533 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 3 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานฝ่ายบริหาร ดังนั้น จำเลยที่ 3 ซึ่งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานฝ่ายบริหาร จึงมีอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 451-1/2534 ที่จำเลยที่ 3 ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษายืน

(ดุสิต เพชรปลูก-อุดม มั่งมีดี-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>